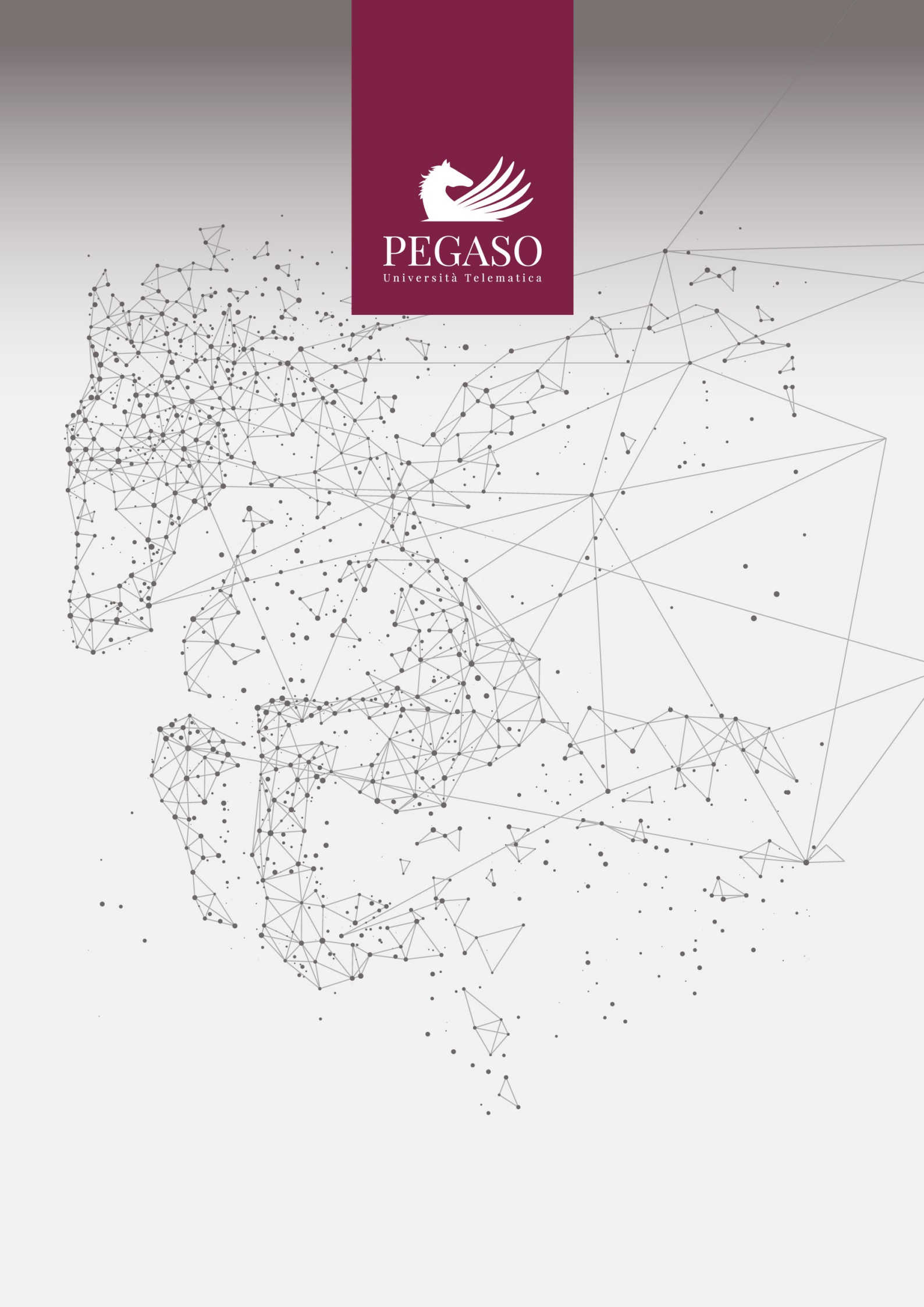

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. PROPRIETÀ INTELLETTUALE: DIRITTO D'AUTORE E DIRITTO INDUSTRIALE 3
2. PROPRIETÀ INTELLETTUALE E DIRITTO COMMERCIALE 5
3. PROPRIETÀ INTELLETTUALE, DIRITTO CIVILE, INTERNAZIONALE E COMPARATO 8
4. PROPRIETÀ INTELLETTUALE, DIRITTO ANTITRUST E *PRIVACY* 13
BIBLIOGRAFIA 15

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Proprietà Intellettuale: diritto d'autore e diritto industriale

Con la locuzione "proprietà intellettuale" si indica – in linea generale – l'insieme di regole giuridiche tese a tutelare i frutti dell'inventiva, dell'ingegno, dell'intelligenza e della creatività umana, subito precisando che non è protetta l'idea in sé, ma (appunto) la sua esterna rappresentazione o applicazione: sempre che, poi, siano integrate le specifiche condizioni di volta in volta previste dalla legge nei singoli casi (diverse per le opere dell'ingegno, i marchi, i brevetti ecc.).

Se tali condizioni sono integrate e sempre in linea generale, la legge attribuisce un vero e proprio "monopolio" nello sfruttamento di quei frutti e appresta vari strumenti per proteggere il titolare da eventuali abusi da parte di soggetti non autorizzati: concedendo un diritto a "struttura proprietaria", che cioè rende il titolare l'unico soggetto abilitato a godere dell'oggetto della protezione (così come il proprietario di un terreno può goderne in via esclusiva) e munito dello *ius excludendi alios*, cioè del diritto di escludere i terzi da tale godimento (così come il proprietario di un fondo lo può recintare e non farvi entrare nessuno, nonché cacciare o far cacciare tutti coloro che vi facciano ingresso senza autorizzazione).

I titolari della protezione e gli oggetti protetti, appena si scenda un po' più nel dettaglio, sono principalmente creatori e inventori con riferimento ai beni immateriali che vengono ad esistenza grazie ad un'attività creativa o inventiva, la quale si estrinseca (principalmente) in opere artistiche e letterarie da un lato, nonché (sempre principalmente) in invenzioni industriali e i marchi dall'altro lato.

Dunque, la proprietà intellettuale identifica una porzione rilevante dell'ordinamento giuridico regolata da principi in parte comuni e che vale la pena di trattare unitariamente intanto

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

per via di tali principi e delle caratteristiche di massima dell'oggetto protetto (come si è detto di carattere immateriale)[1].

Una seconda ragione risiede nel fatto che le relative controversie sono decise dal medesimo giudice, cioè dalle Sezioni Specializzate (ora denominate) per l'Impresa.

Tuttavia, la proprietà intellettuale necessariamente si articola poi nel diritto d'autore, da un lato, nonché nel diritto dei brevetti e dei marchi dall'altro lato, compendiati (questi due ultimi) nella formula "diritto industriale".

Non a caso il nuovo assetto normativo di riferimento (cioè il Decreto Legislativo n. 30 del 2005 – "CPI") è stato intitolato "Codice della Proprietà Industriale" quale testo unico che raccoglie tutte le norme attinenti al campo dei brevetti e dei marchi, dal quale resta fuori la normativa sul diritto d'autore, il cui riferimento principale è ancora la legge 633 del 1941 ("LDA"), con le successive e numerose modifiche.

Si noti che, peraltro, l'evoluzione storica fa sì che la distinzione fra "proprietà industriale" e "proprietà intellettuale" sia molto meno usata all'estero di quanto non lo sia in Italia, soprattutto nei paesi di *Common Law*, nei quali tutte le privative (cioè i diritti a struttura monopolistica aventi ad oggetto i cennati beni immateriali) rientrano tutti nell'alveo della *Intellectual Property*.

Inoltre, l'organizzazione nata sotto l'egida delle Nazioni Unite e nota come Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI) o *World Intellectual Property Organization* (WIPO) che si occupa della negoziazione di nuovi trattati sulla materia ed è responsabile del registro internazionale dei brevetti, non prevede al suo interno una articolazione o bipartizione come quella rispondente a quella italiana diritto d'autore / diritto industriale.

Ciò, tuttavia, non vuol dire che gli oggetti da tali aree protetti non siano assoggettati – anche all'estero e sul piano internazionale – a regole in parte diverse, per cui una loro trattazione separata rimane comunque necessaria.

[1] Senza scendere nel dettaglio, gli economisti affermano che i beni immateriali sono come quelli pubblici (in senso economico) non rivali nell'uso non escludibili nel consumo: una macchina può essere utilizzata da un guidatore per volta, mentre una canzone può essere cantata, una nuova invenzione applicata e un marchio impiegato da moltissime persone allo stesso tempo. Proprio da queste e altre caratteristiche nascono sia gli elementi di vicinanza sia i problemi che accomunano le aree del diritto di cui nel testo.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Proprietà Intellettuale e diritto commerciale

Il diritto a base monopolistica attribuito tramite le privative può risultare assai penalizzante per i terzi, per cui fra chi crea e chi vorrebbe utilizzare liberamente i frutti della creazione vi è un endemico conflitto.

Solo l'autore di una nuova opera (si pensi ad una canzone che diviene un "tormentone"), l'inventore di una nuova invenzione (si pensi ad un certo tipo di cellulare), il creatore di un nuovo marchio (si pensi ad una "griffe" di grande successo nel mondo della moda) può – per un certo tempo – sfruttare in via esclusiva i frutti del proprio genio, escludendo come si è detto tutti gli altri soggetti e persino invocando in certi casi la tutela penale a fronte di un uso non autorizzato.

Tali caratteristiche della proprietà intellettuale espongono a forti critiche taluni settori della disciplina, bastando un attimo per citare i fenomeni – sui quali vi è un sterminata letteratura e che vengono spesso menzionati in dibattiti anche non accademici, di cui una forte eco si trova assai facilmente su *internet* – del passaggio dal *copy-right* al *copy-left* e dalla messa a disposizione di programmi *open source*, cui aggiungere le sferzanti critiche dei sostenitori del *Copy-riot* cioè della rivolta contro il diritto d'autore, all'insegna dello slogan "internet libero" (o affini).

E anche il diritto industriale non va esente da critiche, seppur non così diffuse nella pubblica opinione, ad esempio in relazione ai timori del "controllo sulla vita" che la brevettazione di semi può suscitare, per non parlare delle invenzioni che riguardano più direttamente la vita umana e non solo quella vegetale o animale.

Tuttavia, un aspetto che spesso sfugge oppure é sottovalutato nell'ambito di tali dibattiti afferisce ad un dato fondamentale: l'attribuzione di quel diritto di cui si parlava sopra è la necessaria remunerazione dell'investimento posto in essere dal creatore che, se non fosse così "ripagato", quell'investimento molte volte non lo sosterrebbe affatto, con un grande pregiudizio (in caso di successo) non solo per la sua sfera individuale ma (in ogni caso) per l'intera collettività (perché risorse intellettuali, economiche e di altro tipo non verrebbero indirizzate verso attività creative, inventive e produttive, spesso denominate con l'acronimo R&S, cioè Ricerca e Sviluppo).

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

In tale modo si coglie un primo e forte legame fra proprietà intellettuale e diritto commerciale.

In effetti, l'investimento necessario alla venuta ad esistenza di molti dei frutti sopra indicati – a partire dai brevetti – richiede una organizzazione delle relative risorse e della relativa attività proprio tramite gli strumenti che il diritto commerciale mette a disposizione.

Pertanto, una completa conoscenza della materia richiede altresì, anche in vista della sua applicazione sul piano operativo, la trattazione delle nozioni afferenti all'imprenditore individuale e collettivo, dunque alle società di persone e di capitali, appunto quali forme di organizzazione e gestione delle attività che portano alla nascita dei suddetti beni immateriali e dei correlativi diritti.

In secondo luogo, una volta che tali beni e diritti sono venuti ad esistenza, è spesso tramite un'impresa commerciale ai sensi dell'art. 2082 c.c. che essi vengono sfruttati, cioè tramite "l'esercizio professionale di una un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi", come tale norma recita.

In terzo luogo, quei beni e quei diritti rilevano pure rispetto a specifici elementi di disciplina della impresa commerciale, come ad esempio quelli afferenti al bilancio, come le **immobilizzazioni immateriali**.

Con le necessarie approssimazioni, le immobilizzazioni sono caratterizzate dalla mancanza di tangibilità e sono costituite da costi che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo, ma manifestano i benefici economici durante più esercizi di impresa (di regola delimitati su base annuale).

Esse sono costituite fra le altre cose da **oneri pluriennali** (cioè costi che pur non concretizzandosi nell'acquisizione o produzione interna di beni o diritti possono essere iscritti nell'attivo patrimoniale in virtù del principio di correlazione costi/ricavi) appunto da **beni immateriali** (individuati da attività prive di consistenza fisica che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo amministrativo di riferimento), nonché dall'**avviamento** (che, secondo un'accezione economico-aziendale, può essere definito come quel maggior valore che l'azienda è in grado di produrre per effetto di fattori specifici per i quali il complesso dei beni aziendali ha un valore

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

superiore rispetto alla somma dei singoli beni grazie a elementi – tutti di carattere immateriale – quali la fidelizzazione della clientela, il prestigio, la reputazione dell'azienda, e via dicendo).

Ebbene, poste tali premesse, ai fini della disciplina del bilancio vengono specificamente in considerazione i marchi, i brevetti, i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno (diritti d'autore), il *know how* e il *software*, così essendo evidente quanto sopra si diceva circa il loro rilievo per la disciplina suddetta[2].

In quarto e ultimo luogo, il più stretto momento di collegamento fra la proprietà intellettuale e il diritto commerciale emerge considerando che una serie di istituti della prima nascono proprio per tutelare gli *asset* dell'impresa e compongono l'azienda (esaminata in apposita lezione): come diviene evidente considerando la protezione del *brand* che si realizza tramite il marchio cui si aggiunge la funzione distintiva dei locali e dell'impresa riconducibili alla insegna e alla ditta, disciplinate dal Codice Civile.

Non a caso, del resto, le norme del Codice Civile in materia di diritto industriale e di diritto d'autore sono contenute nel Libro V, cioè in quello (fra i sei libri in cui è appunto diviso il Codice Civile) dedicato alla tutela del lavoro e dell'impresa, vale a dire il libro che contiene la maggior parte delle regole del diritto commerciale.

A riprova di quanto detto, ancora, tutti i testi fondamenti tramite i quali si insegna il diritto commerciale contengono sempre una parte dedicata al diritto d'autore e al diritto industriale.

---

[2] Le modalità di iscrizione in bilancio dei beni indicati possono variare a seconda che la società sia tenuta a redigere il bilancio secondo le disposizioni del Codice Civile così come integrate dai principi contabili italiani pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), oppure secondo quanto previsto dai principi contabili internazionali (IAS e IFRS). Inoltre, occorre tenere conto del fatto che una prima indicazione deriva dall'art. 2424 bis, comma 1, in base al quale "*gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni*", secondo una struttura obbligatoria dello schema di bilancio che suddivide le immobilizzazioni immateriali (voci dell'attivo dello Stato Patrimoniale) nel seguente modo: B.I.1 o B.I.2: costi pluriennali; B.I.3: diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno; B.I.4: marchi, concessioni, licenze e diritti simili; B.I.5: avviamento; B.I.6: immobilizzazioni in corso e acconti; B.I.7: altre immobilizzazioni.
Inoltre, vale la pena di ricordare che secondo l'interpretazione data alla disciplina del Codice Civile fra gli oneri pluriennali rientrano i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità, nonché quelli sostenuti per i diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, mentre le concessioni e licenze di marchi saranno riferiti alla voce dei beni immateriali in senso proprio.
Ancora più in dettaglio, i costi di ricerca e sviluppo sono oneri sostenuti per ottenere nuovi prodotti, processi produttivi, innovazioni tecnologiche ed industriali, ovvero per migliorare in misura significativa i medesimi elementi e si distinguono in ricerca di base (per studi, esperimenti, indagini e ricerche che non hanno una finalità definita con precisione, ma che sono da considerarsi di utilità generica per l'impresa), in ricerca applicata (per studi, esperimenti, indagini e ricerche che si riferiscono direttamente alla possibilità ed utilità di realizzare uno specifico progetto), nonché in sviluppo (per l'applicazione dei risultati della ricerca o di altre conoscenze possedute o acquisite in un progetto o programma per la produzione di materiali, strumenti), cui si aggiungono i costi di pubblicità (fra cui rientrano quelli il lancio di un nuovo prodotto o all'avvio di una nuova attività produttiva).

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Proprietà Intellettuale, diritto civile, internazionale e comparato

Peraltro, oltre ad avere un più stretto legame con il diritto commerciale, la disciplina della proprietà intellettuale deve essere completata con l'esame e la considerazione di una serie di istituti del diritto civile.

Seppur senza una esaustiva rassegna, è ad esempio chiaro che le regole speciali sul risarcimento del danno di cui agli artt. 158 LDA e 125 CPI si devono confrontare con la più generale elaborazione intervenuta appunto in materia civilistica.

La prima delle norme citate, ad esempio, parte dal principio generale per cui "*chi venga leso nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere, oltre al risarcimento del danno che, a spese dell'autore della violazione, sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione*", per poi porre la regola particolare a tenore del quale "*il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile. Il lucro cessante è valutato dal giudice ai sensi dell'articolo 2056, secondo comma, del codice civile, anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto.*

Il giudice può altresì liquidare il danno in via forfettaria sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto", infine aggiungendo che "*sono altresì dovuti i danni non patrimoniali ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile*".

Quanto all'art. 125 CPI, anch'esso contiene chiari riferimenti alle norme generali del Codice Civile prevedendo intanto che "*il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione*", con l'aggiunta per cui "*la sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne*

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso".

Il terzo comma soggiunge ancora che "*in ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento*".

In tale contesto, dunque, le ordinarie regole sul ristoro del danno patrimoniale e non patrimoniale si devono coordinare con le misure speciali in materia di "retroversione degli utili" illegittimamente conseguiti dal contraffattore e con il c.d. prezzo del consenso, cioè con il corrispettivo che egli avrebbe pagato ove vi fosse stato un contratto con il titolare del diritto invece che l'usurpazione delle sue privative.

Vale la pena di fare un secondo esempio.

Il Codice della Proprietà Industriale non contempla una parte relativa ai contratti che intervengono in materia di diritto industriale, mentre la legge sul diritto d'autore prevede solo quelli di edizione per le stampe, quelli di rappresentazione (di un'opera drammatica, drammatico-musicale, coreografica, pantomimica o qualunque altra opera destinata alla rappresentazione) e di esecuzione di opere musicali.

Pertanto, per tutti gli altri contratti – si pensi alla licenza di un marchio, al contratto di produzione industriale che si basi su un brevetto appena concesso, alla contrattualistica di diritti d'autore non toccata delle tre tipologie sopra indicate (ad esempio, quella televisiva o cinematografica) non si potrà prescindere dalla disciplina civilistica e, in specie, dal diritto dei contratti.

Infine, un più stretto legame con il diritto civile lo postulano anche quelle tesi che ricostruiscono il diritto d'autore come diritto della persona di rilevanza costituzionale, la cui violazione – ad esempio – dà sempre vita al risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c. (sopra citato): perché, secondo il più recente orientamento della Corte di

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Cassazione, uno dei casi previsti dalla legge (in cui tale danno può essere riconosciuto, occorrendo allora una specifica previsione di legge in aggiunta agli altri presupposti per il risarcimento del danno in generale) è appunto quello in cui si riscontri la violazione della Legge Fondamentale (cioè della Costituzione).

Venendo al diritto internazionale e comparato, la globalizzazione delle reti e dei mercati rende impossibile svolgere un discorso solo domestico sulla proprietà intellettuale.

Con riguardo al diritto d'autore, è del tutto evidente che *internet* crea immense possibilità di sfruttamento – eliminando in certi settori la stessa catena distributiva che portava dall'autore al fruitore, consentendo un rapporto diretto fra i due – e, al contempo, moltiplica le possibilità di violare un tale diritto: sicché, secondo vari studiosi, nell'era digitale il diritto d'autore è destinato irrimediabilmente a trasformarsi e a non poter essere più configurato come la tradizione lo conosceva.

Un esempio per tutti è rappresentato dalle regole adottate in sede europea con la Direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, la quale ha introdotto nella legge sul diritto d'autore il Titolo II-ter, intitolato "*Misure tecnologiche di protezione. informazioni sul regime dei diritti*", secondo una disciplina che fa il paio con il *Digital Millennium Copyright Act* nordamericano del 1998.

In breve, i titolari proteggono spesso i loro diritti con misure tecnologiche – per limitare gli usi consentiti e attuare "forzosamente" il diritto d'autore – le quali sono a loro volta oggetto di protezione da parte del legislatore (con sanzioni anche penali), ove violate dagli utilizzatori[3].

Inoltre, la dimensione comparata del diritto d'autore induce a non omologare il modello del *copyright* dei Paesi di Common Law a al diritto d'autore continentale, nel senso che ad un "common core" di principi comuni corrispondono poi regole, a volte, significativamente diverse su aspetti che non possono essere ritenuti di dettaglio.

[3] La Direttiva 29/2001 è stata trasposta nell'ordinamento italiano tramite l'emanazione del D.Lgs. 68/2003, sul quale si vedano, per tutti, G. SENA, P. FRASSI, G. D'AMMASSA, S. GIUDICI, D. MINOTTI e F. MORRI, *Diritto d'autore e diritti connessi nella società dell'informazione*, *Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 68 in attuazione della Direttiva 2001/29/CE*, Milano, 2003, nonché, con particolare al riguardo al problema del bilanciamento fra misure tecnologiche di protezione ed utilizzazioni libere, V.M. DE SANCTIS, *La copia privata nel d.leg. 68/2003 - Prime valutazioni (relazione al seminario Agica del Mifed 2003)*, in *Dir. aut.*, 2004, 115 ss.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Con riguardo al diritto industriale, poi, si riscontra una standardizzazione a livello mondiale circa le regole che proteggono i suoi "oggetti" fondamentali – come le invenzioni, i marchi, i modelli e via dicendo –, sicché le ipotesi di istituti che trovano riscontro in un ordinamento e non in un altro sono eccezionali.

Ciò vale, ad esempio, per i modelli di utilità, adottati all'inizio del XX Secolo anche in Giappone a seguito della sua "modernizzazione", attraverso un fenomeno di circolazione delle regole che trova il proprio epicentro nell'ordinamento tedesco.

Tale sistema, infatti, è stato il primo a disciplinare espressamente i modelli di utilità con una legge del 1891 alla luce di un'esigenza da non sottovalutare: quella di proteggere i trovati di minore importanza per i quali non era possibile richiedere la tutela né ai sensi della legge del 1876 relativa ai disegni e modelli industriali (interpretata dalla giurisprudenza nel senso di limitare il proprio oggetto alle creazioni estetiche), né ai sensi della legge del 1877 relativa alle invenzioni: la quale, d'altronde, prevedeva una procedura con costi e lungaggini incompatibili con l'esigenza di disporre in tempi brevi – almeno per certi tipi di prodotti – della tutela brevettuale.

E tali esigenze ne spiegano probabilmente l'introduzione anche nel sistema italiano a poca distanza dall'adozione della citata normativa tedesca: in specie, con il r.d. 13 settembre 1934, n. 1602, che non entrò mai in vigore e, poco dopo, con un regio decreto del 1940 (rimasto in vigore fino all'emanazione del Codice della Proprietà Industriale).

Tra l'altro, tornando al sistema tedesco, è significativo che una delle finalità perseguite dal legislatore sia stata espressamente rinvenuta dalla dottrina nel tentativo di far diminuire le domande per brevetto di invenzione ed evitare che tale strumento fosse utilizzato per trovati che erano il frutto di un minore sforzo inventivo (per intenderci, se il coltello con lama d'acciaio è certamente una invenzione, la modifica che fa diventare la lama "seghettata" per aumentarne l'efficacia è da proteggere con un modello e richiede una valutazione, in parte, più semplice).

D'altronde, la stessa circostanza per cui la legge è stata nel tempo modificata varie volte e poi sostituita con nuove versioni dimostra che gli operatori hanno più o meno costantemente avvertito l'utilità del regime di protezione offerto dalla suddetta privativa (cioè dal modello di

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

utilità), sicché tale istituto – conosciuto anche dal legislatore italiano – trova comunque una propria collocazione nel sistema giuridico.

In sintesi, gli esempi fatti dimostrano che la proprietà intellettuale non può essere approfonditamente studiata e compresa obliterando la sua dimensione transnazionale e gli strumenti offerti dal diritto comparato.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

4. Proprietà Intellettuale, diritto antitrust e *privacy*

Con riguardo al diritto *antitrust*, la stessa struttura monopolistica delle privative industrialistiche e autoriali non è facilmente armonizzabile con le regole poste a tutela della concorrenza e del mercato.

Un esempio può chiarire il punto. Un atto di esercizio di un diritto di IP – ad esempio quello "tipico" consistente nel rifiuto di dare un diritto in licenza – è assolutamente legittimo sotto il profilo del diritto dei contratti e della libertà di chiunque di negoziare con chiunque (voglia).

Ma se quell'atto è posto in essere da un soggetto posto in posizione dominante – basta un secondo per richiamare la casistica *antitrust* che ha coinvolto Microsoft, per la quale si trovano amplissimi riferimenti su *internet* – esso può configurare un abuso di tale posizione.

Il dibattitto è quanto mai acceso ed ampio, con posizioni assai diversificate:

1. alcuni affermano un aprioristico primato delle privative rispetto all'*antitrust*, configurando le stesse quale *leges speciales* in relazione al primo e postulando una "convergenza finalistica" delle due discipline;
2. altri, all'opposto, invocano una prevalenza della seconda in base ad una sostanziale equiparazione fra i beni oggetto di diritti di proprietà intellettuale e altri diritti;
3. altri ancora tentano un confronto paritario fra le discipline sul terreno della *cost-benefit-analysis*, dando prevalenza all'una o all'altra in ragione di tale valutazione;
4. si finisce con la posizione di chi invita a pensare ad un intervento di carattere regolatorio ([4]).

Peraltro, anche solo in ordine al modo di "interpretare" i responsi dei giudici non vi è concordia, in quanto secondo alcuni autori essi stanno in prevalenza assegnando prevalenza alle privative su entrambe le sponde dell'oceano.

Ma il fiorire di pronunce difficili da far convivere assieme sembra piuttosto doversi spiegare con una evoluzione tutt'altro che recessiva della giurisprudenza *antitrust*, perlopiù dipendente dalle differenze delle singole fattispecie concrete.

[4] Si vedano, per una sintesi delle posizioni citate, R. PARDOLESI e M. GRANIERI, *Proprietà intellettuale e concorrenza: convergenza finalistica e* «liaisons dangereuses», in *Foro it.*, 2003, V, 193 ss.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Pertanto, non si può allo stato affermare che la giurisprudenza è attestata su posizioni definitive in ordine al predetto e difficile rapporto.

Quanto poi alla *privacy*, il termine appena evocato indica nell'ordinamento italiano e non solo due distinti concetti, l'uno relativo alla riservatezza della vita privata, l'altro relativo al controllo e alla gestione di informazioni che afferiscono alla persona.

Si tratta evidentemente di settori di disciplina assai rilevanti per le imprese commerciali, sol che si pensi agli oneri e adempimenti sempre maggiori che la normativa italiana e comunitaria impongono in materia di trattamento dei dati personali.

Inoltre, sia il diritto alla *privacy* in senso tradizionale sia quello "proprietario" sui propri dati – la cui violazione può portare (anche qui) a richiedere e ottenere il risarcimento del danno – richiedono (di nuovo) di essere messi in relazione alla elaborazione civilistica, oltre a incrociare la via della proprietà intellettuale sotto vari aspetti: ad esempio, considerando la possibilità di un utilizzo senza consenso (o no) dell'immagine di una persona ai sensi degli art. 96 e 97 LDA, nonché la necessità di assoggettare tale consenso alle medesime regole richieste per il trattamento dei dati (dacché l'immagine può essere considerata sia l'oggetto di uno dei tradizionali diritti previsti dal Codice Civile e dalla LDA, sia un dato personale assoggettato alla disciplina sul trattamento dei dati personali).

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- V. M. De Sanctis (a cura di), *Il codice della proprietà industriale e la protezione delle forme*, Milano, Giuffré, 2009;
- B. Tassone, *DRM e rifiuto di licenza nel caso Virgin v. Apple: questione di FairPlay?*, in *Annali Italiani del Diritto D'Autore*, 2005, pp. 376-390.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).